



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4229/2017/2/CA1

Paraná, 19 de octubre de 2.017.

Y VISTO: en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Mateo José BUSANICHE, Presidente; el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Vicepresidente; y la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Jueza de Cámara, en el Expte. N° FPA 4229/2017/2/CA1, caratulado: "LEGAJO DE APELACION DE RAMIREZ, HORACIO ARIEL EN AUTOS RAMIREZ, HORACIO ARIEL POR INFRACCION LEY 23.737", provenientes del Juzgado Federal N° 1 de esta ciudad, y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Mateo José Busaniche, dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Horacio Ariel Ramírez a fs. 8/11 vta., contra la resolución obrante a fs. 1/7, en cuanto procesa al nombrado, por el hecho por el cual fuera indagado, tenencia de estupefacientes para consumo personal, previsto y reprimido por el art. 14, 2da. parte de la ley 23.737, art. 45 Cód. Penal y de conformidad a los arts. 306 y 308 del CPPN. El recurso fue concedido a fs. 12.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 23 y vta., compareciendo en la oportunidad el Sr. Fiscal General de Cámara, Dr. Ricardo Carlos María Álvarez;



y el Sr. Defensor Público Oficial Coadyuvante, Dr. Alejandro Joaquín Castelli, en defensa de Horacio Ariel Ramírez; quedando los presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- a) Que, el Sr. Defensor Público Oficial Coadyuvante Castelli solicita se revoque la resolución recurrida. Reseña el hecho que diera origen a las actuaciones y destaca el lugar donde fue habido el tóxico y su cantidad.

Remite al recurso interpuesto y cuestiona que no considere aplicable el fallo Arriola. Sostiene que declararse la atipicidad de la conducta, al tratarse de una pequeña cantidad de estupefaciente en un lugar de privacidad, resaltando que fue necesaria una requisita para descubrirla.

Indica que la requisita fue plasmada en un acta que no se realizó de acuerdo a lo prescripto por el art. 138 del CPPN, al no haber testigos.

Alega que no se afectó a terceros y cita jurisprudencia de la CFCP y la CSJN y del Tribunal oral de esta ciudad. Concluye que no se puede presumir que la tenencia en un establecimiento carcelario lesione a terceros y a la salud pública. Solicita se revoque la resolución recurrida y se dicte el sobreseimiento de Ramírez por la atipicidad de la conducta. Hace reserva de casación.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4229/2017/2/CA1

b) Por su parte, el Sr. Fiscal General reseña el hecho que diera origen a las actuaciones y considera que la figura que se le atribuye luce correcta.

Refiere al criterio de esta Alzada respecto de los recursos de apelación contra la calificación jurídica y efectúa consideraciones al respecto.

Refiere a la situación de los penitentes, indica que no tienen el mismo disfrute de derechos que un ciudadano y alude al ámbito de intimidad. Cita doctrina y destaca que es pacífico el criterio de este Tribunal al respecto. Concluye que no puede tratarse igual que a una persona en libertad y menciona la trascendencia inevitable a terceros. Reitera que la calificación del juez es la correcta y que no se da en el caso las circunstancias del fallo Arriola.

Propicia se rechace el recurso y se confirme la resolución recurrida.

II- Que, las presentes actuaciones reconocen su inicio el 22/03/2017 a las 12:35 horas aprox., cuando agentes de la Unidad Penal N° 1 llevaron a cabo una requisa corporal al interno penado Horacio Ariel RAMÍREZ, en ocasión de regresar de su salida socio familiar, constatándose que el mencionado portaba en el interior de su zapatilla izquierda y envuelta en una servilleta de papel



sustancia vegetal de color verde amarronada y semillas -presumiblemente marihuana-.

Instruidas las actuaciones, se realizó la pericia química que determinó que se trataba de marihuana en la cantidad total de 3,01 gramos, y el 06/06/2017 fue indagado Ramírez, decretándose su procesamiento el 28/08/2017, contra lo cual se alzó la defensa, dando lugar a esta instancia.

III- a) Que, en primer término, cabe dar tratamiento a las alegaciones de la defensa en cuanto cuestiona que la requisita fue plasmada en un acta que no se realizó conforme lo establece el art. 138 del CPPN.

Al respecto cabe señalar que de la lectura del Acta de Secuestro obrante a fs. 2 de las actuaciones, surge que fue realizada con la presencia de los agentes penitenciarios Eladio Cardoso y Diego Ifran, *"ambos funcionarios con domicilio laboral en la Unidad Penal N° 1... Utilizados ante la no disponibilidad de civiles por el lugar y la hora que se desarrolla el acto"*.

Adviértase que los agentes penitenciarios, como funcionarios de la provincia de Entre Ríos, expresaron los motivos por los cuales no se contaba con testigos civiles y que dio lugar a que intervinieran funcionarios de la misma repartición en tal calidad en el acta de secuestro.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4229/2017/2/CA1

Sin perjuicio de ello, cabe tener presente que, en oportunidad de prestar declaración testimonial los agentes Hernán Ignacio Moreno y Diego Ismael Segovia, quienes requisaron al interno Ramírez en ocasión de regresar de su salida socio familiar, dieron cuenta de lo acontecido y reconocieron los efectos que le secuestrarán al imputado y que les fueran exhibidos, todo lo cual permite reconstruir los hechos aquí se investigan (cfr. fs. 47 y vta., y 76 y vta., respectivamente).

Por otro lado, no debe perderse de vista que el art. 140 del C.P.P.N. sólo contempla como causal de nulidad del acta la carencia de la firma de los testigos, cuando del contenido de aquella surge la concurrencia de los mismos a su otorgamiento, distinguiendo la cuestión de la validez del acta en tanto instrumento público, con aquella atinente al valor probatorio de la misma.

Que, una razonable interpretación -a esta altura de la investigación-, sería aquélla conforme la cual las aparentes irregularidades no afectan el normal desenvolvimiento del procedimiento, pues todo ha quedado debidamente documentado, por lo que, el marco fáctico puede ser perfectamente reconstruido, siendo prematuro postular la nulidad del proceder con este sólo argumento.

En este estado, cabe recordar una vez más que es criterio de esta Alzada que la nulidad es un

Fecha de firma: 19/10/2017

Alta en sistema: 24/10/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30429577#191371849#20171019121845247

recurso extremo y, como tal, "requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el solo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia" (L.S.Crim. 2006-II-317), a lo que cabe aditar que "toda nulidad necesariamente debe lesionar, cualquiera sea la intensidad del menoscabo, una garantía constitucional..." (L.S. Crim. 2000-II-469, entre muchos otros).

b) Sentado aquello, adentrados al tratamiento de la materia de agravios venida a resolver, debe señalarse que el Máximo Tribunal resolvió en el citado precedente "Arriola", la declaración de inconstitucionalidad del art. 14, segunda parte, de la ley 23.737, en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros.

Cobra especial relevancia, cuanto refiere la Dra. Argibay en su voto - considerando 13- en el mentado precedente: "(...) La síntesis expuesta muestra que si bien las acciones privadas no son solamente aquellas que se llevan a cabo en el interior de un determinado ámbito espacial, este dato, resulta, sin embargo, un elemento de juicio a tomar en consideración. Efectivamente, el análisis





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4229/2017/2/CA1

casuístico deja entrever que las conductas desarrolladas en lugares públicos, son, en general aunque no siempre, más aptas para afectar la salud pública, y por lo tanto quedan fuera de la protección constitucional.

Por otro lado, y aunque este dato es un indicio relevante, no resulta suficiente para decidir la cuestión. Otro elemento que en los fallos citados ha sido significativo para determinar si la tenencia de drogas se trata de una acción privada está relacionado con la existencia de actos de exhibición en el consumo. Esto no se cumple cuando la acción ha sido descubierta no por la tenencia de la droga en sí sino por un hecho ajeno a esa conducta. Por último, también ha tenido incidencia la cantidad de la sustancia estupefaciente que se encontró en poder de la/el imputada/o.

(...) En conclusión, la adhesión a los postulados sentados en "Bazterrica" implica que los jueces de la causa deberán analizar en el caso concreto si la tenencia de estupefaciente para consumo personal se realizó en condiciones tales que trajo aparejado peligro concreto o daños a bienes o derechos de terceros, que le quiten al comportamiento el carácter de acción privada protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional (...)."

Fecha de firma: 19/10/2017

Alta en sistema: 24/10/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30429577#191371849#20171019121845247

En seguimiento de tales premisas, debe atenderse en el caso, al contexto en que se detectó la tenencia del material estupefaciente; esto es, al efectuarse una requisa corporal al interno Horacio Ariel Ramírez, en ocasión de regresar de su salida socio familiar, en la Unidad Penal N°1 de esta ciudad.

Es que el ámbito donde se produjo el secuestro dota de connotaciones específicas a la tenencia del tóxico. Surge evidente que la esfera de privacidad de un interno no goza de la dinámica propia de un domicilio particular, pues si se repara en las condiciones en que se cumple una pena privativa de libertad, el riesgo de difusión, suministro y la posibilidad de compartir la sustancia prohibida, convierte este acontecimiento en una acción que, si bien vislumbra su destino privado, no puede ocultar su idoneidad propagativa (cfr. en tal sentido L.S.Crim. 2012-I-178; 2009-II-804, entre muchos otros).

Por ello, atendiendo al contexto en que el hecho delictivo tuvo lugar, es dable suponer un grado mayor de "propagación de riesgo", importando la presunta tenencia de estupefacientes de Horacio Ariel Ramírez un daño o peligro concreto a terceras personas, por lo que su punición no contraría garantía constitucional alguna, debiendo por ello





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4229/2017/2/CA1

rechazar el recurso interpuesto por la defensa del nombrado y confirmar la resolución recurrida.

El **Dr. Daniel Edgardo Alonso**, dijo: Y VISTO:..., Y CONSIDERANDO: I-..., II-..., III-a)..., b) Que, no comparto la solución a la que arriba mi distinguido colega preopinante. Ello así por considerar que en el caso no hubo afectación al bien jurídico protegido salud pública.

Al respecto, cabe referir al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "ARRIOLA". Lo allí señalado por el cimero Tribunal -respecto de la ineptitud de la persecución penal respecto de consumidores- nos exime de mayores comentarios.

Sin embargo, destaco que en el presente caso no se trata de recurrir a la grave decisión de declarar la inconstitucionalidad de la norma, sino, en todo caso, de la adecuada subsunción jurídica de la conducta enrostrada.

En tal inteligencia, sostengo que no puede considerarse legítima una restricción estatal por la mera prohibición contenida en la ley penal, porque si fuera aceptada aún en los casos en que no se verifica la afectación al bien jurídico en que se fundamenta la punibilidad de ese tipo de hechos, se habilitaría la intervención punitiva excediendo el marco de interpretación restrictiva de justificación



a la intromisión estatal en los derechos individuales que fuera reseñado.

Así, por más que se trate de un delito de peligro abstracto, y esté ínsita en su descripción típica la trascendencia a terceros y la consecuente afectación a la salud pública (CSJN, Fallos: 313:1333, considerando 12), el caso concreto que se ha criminalizado debe ser representativo de ese riesgo potencial para el bien jurídico definido en la figura.

Que, es preciso recordar que las presunciones de riesgo contenidas en los delitos de peligro son consideradas constitucionalmente inaceptables, ya que por definición sirven para dar por cierto lo que es falso, o sea, para considerar que hay ofensa cuando no la hay. Por ello, el análisis de los tipos penales en el ordenamiento vigente y por imperativo constitucional, debe partir de la premisa de que en los tipos de peligro siempre debe haber existido una situación de riesgo de lesión en el mundo real (Eugenio R. Zaffaroni - Alejandro Alagia- Alejandro Slokar, "Derecho Penal. Parte General", Ediar, pág. 469, Buenos Aires, 2000).

La exigencia de que se constate esa situación de riesgo no significa incorporar elementos en el tipo penal -un resultado exterior a la conducta- que no fueron incluidos en la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4229/2017/2/CA1

descripción efectuada en la ley. Es que no se trata de que se produzca un efectivo peligro como si fuera un delito de peligro concreto, en los que el tipo requiere como resultado de la acción la proximidad de una concreta lesión, sino de analizar la peligrosidad de la conducta, que se supone inherente a la acción salvo que se pruebe que en el caso concreto quedó excluida de antemano (Mir Puig, Santiago, "Derecho Penal. Parte General", 5ta. edición, págs. 209/10, Barcelona, 1998).

Así, sólo en el caso de algunos delitos de peligro abstracto que tienden a la protección de ciertos bienes jurídicos supra individuales, se acepta prescindir de la necesidad de constatar la peligrosidad de la acción en relación con el bien inmaterial que se protege. En esos casos se trata de proteger bienes jurídicos de carácter inmaterial o institucionalizado, esenciales para el desenvolvimiento de la vida social, institucional o económica, cuyo menoscabo se produce -más que por cada acto individual- por la reiteración generalizada de conductas que no respetan las reglas básicas que aseguran el sistema y su funcionamiento (Rodríguez Montañés, Teresa, "Delitos de peligro, dolo e imprudencia", Rubinzal-Culzoni Editores, págs. 354/6 y 398, Buenos Aires, 2004. Ver también, Roxin, Claus, "Derecho Penal. Parte General",



Civitas, págs. 410/1, Madrid, 1997, ejemplificando con los delitos de cohecho y falso testimonio).

En cambio, en los delitos de peligro abstracto (propios) en los que se aprecia una relación más o menos inmediata con bienes jurídicos individuales o individualizables, la regla es que la realización de la conducta típica lleve implícita la peligrosidad, pero quedará excluida la tipicidad cuando excepcionalmente no se presente esa peligrosidad que caracteriza -en general- a esa clase de conductas. En este grupo se incluye a los delitos contra la salud pública, en tanto tienden a proteger las condiciones necesarias para hacer posible la salud individual de un grupo social, como una colectividad más o menos difusa (Rodríguez Montañés, op. cit., págs. 359/66 y 398/9).

La caracterización de la salud pública como bien jurídico colectivo indica que la potencialidad de una conducta para afectarlo se configura si ésta se proyecta sobre la comunidad y las personas de manera general e indeterminada.

Se advierte un particular problema en distinguir la vinculación de la tenencia de sustancias estupefacientes para uso personal con la afectación a la salud pública, ya que la descripción típica contiene un especial elemento subjetivo que determina la necesidad de acreditar





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4229/2017/2/CA1

que la droga es poseída con la finalidad de ser consumida.

Si bien esa finalidad conduce a pensar que, en principio, sólo es la salud individual del sujeto la que se encuentra en riesgo, la salud pública como interés colectivo puede considerarse afectada cuando la tenencia de las sustancias estupefacientes no se adecue a lo que podría considerarse una actividad de consumo privado e individual. Así, es posible afirmar que existe una razonable apreciación de peligrosidad que trasciende ese ámbito cuando la tenencia de la droga se enmarca en una situación de consumo potencialmente dañosa o de posible difusión indeterminada de los estupefacientes.

En particular, sobre la posibilidad de propagación de la droga a través del consumo cabe reparar en que, aun cuando se haya afirmado que es un dato extraído de la experiencia general en esta materia, no se presenta en algunos casos en los que se evidencia con claridad que el sujeto tenía esa sustancia para ser usada en privado y/o sin involucrar a un conjunto indefinido de individuos. Esa tenencia no puede considerarse atrapada por el tipo penal descripto en el artículo 14 segundo párrafo de la ley 23.737, porque ha quedado descartado el riesgo potencial para la salud pública



que puede fundamentar la punibilidad de ese tipo de hechos.

Que, ello sucedería en el presente caso, pues de la exigua cantidad de estupefaciente incautado, no surgiría elemento alguno que permita imputar la finalidad de desarrollar un consumo que trascienda a un número indeterminado de personas.

Por lo demás, el intento de ingreso de la sustancia al establecimiento carcelario, luego de que el imputado regresara de una salida socio familiar, estaba condenado al fracaso en virtud del estricto régimen al que los internos son sometidos antes de reingresar o ingresar.

En efecto, la requisita previa al ingreso determinó la incautación de la sustancia prohibida, de lo que se sigue que no estuvo -ni pudo haber estado jamás- en riesgo el bien jurídico tutelado, excepto que pongamos en crisis el adecuado cumplimiento de sus funciones por parte del personal del Estado afectado a los controles.

A la luz de estas consideraciones, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, y decretar el sobreseimiento de Horacio Ariel Ramírez, por el hecho por el que fue indagado, en razón de resultar atípica la conducta desarrollada, siendo innecesaria la declaración de inconstitucionalidad.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4229/2017/2/CA1

La Dra. **Cintia Graciela Gómez**, dijo: Que
adhiera a la solución propuesta por el Dr.
Busaniche.

Que, en mérito al resultado del Acuerdo
que antecede, por mayoría, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación
interpuesto por la defensa del imputado Horacio
Ariel Ramírez y confirmar la resolución obrante a
fs. 1/7, que procesa al nombrado por el delito de
tenencia de estupefacientes para consumo personal,
de conformidad a los argumentos vertidos en los
considerandos precedentes.

Regístrese, notifíquese, difúndase a
través de la Dirección de Comunicación Pública de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y,
oportunamente, bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

